

1500350-18.2020.8.26.0452

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... em outros crimes, sobretudo furto e tráfico de drogas, tendo localizado ambos juntos pouco tempo depois, na Rua Carlos Eduardo Justo; em abordagem, o telefone celular subtraído foi encontrado no bolso de "Deca"; indagado, "Deca" admitiu ter pegado o telefone da vítima, mas se mostrou indignado ao saber que iria para a Delegacia por conta de "apenas um celular"; Carlinhos não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

2ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500350-18.2020.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500350-18.2020.8.26.0452

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2133332/2020 - DEL.POL.PIRAJU, 11675533 - DEL.POL.PIRAJU, 603/20/118 - DEL.POL.PIRAJU, 2133332 - DEL.POL.MANDURI, 603/20/118 - DEL.POL.MANDURI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE JOSE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ANDRÉ JOSÉ DA SILVA, vulgo "Deca", e CARLOS EDUARDO MACHADO, vulgo "Carlinhos" (fls. 115/116), qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º de junho de 2020, por volta das 18h30, na Rua Carlos e Justo, Conjunto Habitacional Prefeito Pedro Pri, na cidade de Manduri, comarca de Piraju, ANDRÉ JOSÉ DA SILVA, vulgo "Deca" e CARLOS EDUARDO MACHADO, vulgo "Carlinhos", qualificado a fls. 5 e 6, respectivamente, agindo em concurso, subtraíram, mediante violência, o celular Samsung/A10, avaliado em R\$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal de fls. 10, pertencente à vítima Paulo César Ribeiro.

Ao que se apurou, os denunciados estavam juntos quando no local chegou a vítima, pedindo para que ANDRÉ devolvesse o celular Samsung/J4 que havia deixado em garantia com ele em troca do empréstimo de cinquenta reais.

Nesse momento, ANDRÉ não só se recusou a devolver o celular como violentamente

avançou contra a vítima e a arremessou contra a parede, quebrando o vidro do local com o impacto do corpo contra tal superfície. Ainda, tal denunciado tentou desferir um soco contra a vítima, que por pouco não foi atingida.

Nesse momento, enquanto ANDRÉ estava em luta corporal com a vítima, imobilizando-a, CARLOS dela se aproximou e subtraiu o celular de seu bolso.

Ato contínuo, a vítima escapou correndo, sendo perseguida por ANDRÉ por aproximadamente um quarteirão, conseguiu fugir até a sua residência, onde acionou a polícia e relatou o ocorrido.

Pouco tempo depois policiais chegaram ao local e encontraram os denunciados de posse da res furtiva (fls. 12), localizada bolso de ANDRÉ, que foi reconhecida pela vítima como sendo sua (fls. 13) e a ela devolvida (fls. 14). (fl. 115).

A denúncia foi recebida em 18.06.2020 (fl. 117).

Regularmente citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 178/194).

Em não se entrevendo hipótese de absolvição sumária, ratificou-se o recebimento da denúncia e designaram-se audiências de instrução e julgamento.

Em sede instrutória, colheu-se a prova oral, e as partes apresentaram suas alegações finais (termos e mídias audiovisuais das audiências).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial improcede.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal). "A sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64). Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do Código de Processo Penal).

Como anota PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR, 'o roubo só foi previsto em sua modalidade dolosa. Consiste o dolo na consciência e vontade de praticar uma violência, física ou moral, para subtrair coisa alheia móvel. Afora o dolo genérico, ainda se faz necessário o dolo específico, que reside na intenção de conservar a coisa alheia para sempre. O dolo específico se deduz da expressão normativa "subtrair para si ou para outrem", que pressupõe a intenção de posse definitiva.' (Comentários ao Código Penal, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 478).

No caso concreto, não foram coligidas em juízo provas cabais da presença do elemento subjetivo especial do injusto (fim de ter a coisa para si ou para outrem). Na fase investigativa, a vítima Paulo César Ribeiro declarou que: conhece "Deca" e Carlinhos, vulgo "Budinha"; dias atrás, havia entregado outro telefone celular da marca Samsung, modelo J4, para "Deca", como garantia de um empréstimo de R\$ 50,00; recentemente, pagou os "R\$ 50,00" a "Deca", mas não teve o seu telefone móvel devolvido; na data dos fatos, no final da tarde, procurou "Deca", a fim de pedir a devolução do celular, já que ainda está pagando as prestações do produto; "Deca" estava na companhia de Carlinhos, vulgo "Budinha", e se recusou a devolver o celular; ato contínuo, "Deca", que é fisicamente grande e forte, jogou-o contra a

parede, quebrando o vidro com o impacto de suas costas, desferiu-lhe um murro e o segurou pelo pescoço, ao tempo em que “Budinha” se aproximou e pegou do seu bolso um telefone celular da marca Samsung, modelo A10, de cor azul; conseguiu escapar e saiu correndo; “Deca” correu atrás de si por aproximadamente um quarteirão, mas depois desistiu de persegui-lo; foi até a sua casa e acionou a Polícia; pouco tempo depois, os policiais militares chegaram ao local; contou os fatos aos milicianos, que saíram em patrulhamento; pouco tempo depois, os policiais retornaram com os increpados, mostraram-lhe um telefone celular, modelo A10, que fora encontrado com “Deca”, bem que foi imediatamente reconhecido por ele como sendo o aparelho subtraído pouco tempo antes; o bem foi restituído (fl. 4).

Em juízo, Paulo contou, em suma, que: entrou em luta corporal com André; em virtude disso, o aparelho celular possivelmente caiu do seu bolso, ao que os réus devem ter subtraído o bem; faz uso de drogas e álcool; os acusados não se valeram de violência física contra si (mídia audiovisual da primeira audiência).

Na fase investigativa, os policiais militares Rogério Leme de Freitas e Robson José Valério relataram, em uníssono, que: estavam de plantão quando, por volta das 18h, receberam via COPOM a notícia de roubo ocorrido na Rua Acre, no Município de Manduri; dirigiram-se até o local indicado, onde encontraram a vítima, Sr. Paulo César Ribeiro, a qual lhes reportou que os indivíduos conhecidos por “Deca” e Carlinhos “Budinha” haviam subtraído seu telefone celular, da marca Samsung, modelo A10, por meio de violência; o ofendido narrou que “Deca” o empurrou com violência, chegando a quebrar uma janela com o impacto das suas costas, deu-lhe um soco e, em seguida, segurou-o por trás, pelo pescoço, sufocando-o, enquanto Carlinhos pegou o celular do seu bolso; a vítima informou fazer uso de crack e não ter sofrido lesões físicas decorrentes da violência empregada durante a subtração; passaram a procurar os implicados, já conhecidos dos meios policiais por envolvimento em outros crimes, sobretudo furto e tráfico de drogas, tendo localizado ambos juntos pouco tempo depois, na Rua Carlos Eduardo Justo; em abordagem, o telefone celular subtraído foi encontrado no bolso de “Deca”; indagado, “Deca” admitiu ter pegado o telefone da vítima, mas se mostrou indignado ao saber que iria para a Delegacia por conta de “apenas um celular”; Carlinhos não se manifestou; a vítima reconheceu o telefone celular apreendido (fls. 2 e 3).

Em juízo, compromissados, os milicianos reproduziram, em essência, os relatos extrajudiciais, minudenciando as diligências que resultaram na prisão em flagrante dos acusados. Esclareceram que a vítima não apresentava lesões corporais aparentes (mídia audiovisual da segunda audiência).

Jorge Ribeiro da Silva, pai do acusado André, ouvido como informante do Juízo, disse que: não presenciou os fatos sob apuração, apenas ficou sabendo que as partes brigaram, tendo os réus pegado o celular da vítima; acusados e vítima são amigos, sendo todos usuários de drogas; o filho dele comumente fica internado por uso de drogas; o filho e a vítima sempre andavam juntos (mídia audiovisual da segunda audiência).

Na fase investigativa, os imputados quedaram silentes (fls. 5 e 6).

Interrogado em juízo, o acusado Carlos Eduardo Machado negou os fatos imputados. Alegou que: a vítima havia dado um celular J4 a André como empréstimo; Paulo foi atrás do aparelho móvel; não retiraram o celular do bolso do ofendido; o bem caiu no chão, pegaram-no e esperaram a vítima voltar para devolvê-lo; os policiais os abordaram no dia seguinte, ocasião em que o celular estava com André; este e a vítima eram amigos; no dia dos fatos, estavam bebendo todos juntos (mídia audiovisual da segunda audiência).

O interrogatório judicial de André José da Silva restou prejudicado, porquanto revel.

Como se vê, não restou evidenciado que os réus agiram imbuídos do fim de conservar o celular para si ou para outrem de forma definitiva. A versão apresentada pelo réu Carlos no sentido de que pegaram a coisa que caíra no chão ao ensejo de discussão travada entre André e Paulo não foi completamente refutada pelo último nesta sede judicial.

Tampouco se cogita – diversamente do sustentado em alegações finais pelo nobre representante do Ministério Público – de condenação dos acusados por furto. Ainda

que se atribua definição jurídico-legal diversa à conduta descrita na denúncia, o que tem amparo na regra do art. 383 do Código de Processo Penal, a responsabilização criminal esbarraria, também, na anemia probatória em torno do elemento subjetivo do tipo penal. No furto, “o tipo subjetivo está fundado no dolo, elemento subjetivo genérico geral (dolo genérico, para a escola clássica), que é a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, e no elemento subjetivo especial do tipo subjetivo de injusto (dolo específico), que é o fim de ter a coisa para si ou para outra pessoa. Não é necessário que o agente vise o lucro ou vantagem ilícita. Para que se configure o crime de furto é necessário que o agente tenha o conhecimento de que a coisa alheia não é sua, caso contrário a conduta será atípica pela exclusão do dolo, por consubstanciar erro sobre elemento do tipo (art. 20 do CP).” (MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA e MARTA SAAD, (Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência, 8ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 782). Não há nos autos elementos de convicção bastantes para que se conclua que os acusados realmente premeditaram o intento de subtrair coisa alheia móvel, em prejuízo da vítima (animus furandi).

Nesse quadro, a ação incriminada tem respaldo tão somente em elementos informativos colhidos nos autos do inquérito policial, os quais não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, a teor do art. 155 do Código de Processo Penal. Na lição de EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER:

'Elementos informativos e elementos probatórios: Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio.

A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notitia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos.

Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

A nova redação do art. 155, trazida pela Lei nº 11.690/08, inova. E, para pior, a depender da extensão de sua aplicação.

Diz o texto: “não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. O que significaria isso?

Em primeiro lugar, é de se atentar para o fato de que a expressão “exclusivamente” não constava do anteprojeto original que veio a se transformar na Lei nº 11.690/08. A ideia inicial era afastar qualquer possibilidade de valoração de material probante produzido unicamente na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares que não pudessem ser repetidas no curso da instrução (interceptações telefônicas, perícias em que já perecido o objeto da prova etc.). Com o acréscimo (do “exclusivamente”), levanta-se, mais uma vez, a questão acerca da possibilidade de formação de convencimento judicial com base em elementos informativos produzidos na investigação.

É de se ver, então, que a inexistência de contraditório e de ampla defesa na fase de investigação preliminar, em princípio, impede a valoração judicial de tais elementos (informativos). Como regra, é claro, já que existem provas, ressalvadas inclusive na citada Lei nº 11.690/08, cuja natureza intrínseca não permite a sua reprodução em juízo. Não se pode, por exemplo, reproduzir a conversa captada em uma interceptação telefônica. Do mesmo modo, não se realiza prova pericial quando o objeto a ser periciado já não se encontra mais à disposição. E, nada obstante, tais meios de prova são aceitos aqui e, provavelmente, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos.

É que, em tais situações, o contraditório é diferido, ou seja, é adiado – da fase de investigação para a fase de instrução – permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas, do ponto de vista jurídico ou tecnológico, àquele material realizado sem o controle judicial. Por certo que a qualidade das objeções é reduzida, na medida em que se cuida de questionamentos pos factum, sem o alcance das percepções imediatas, em tempo real.

Mas, diante da relevância e da gravidade dos danos causados pela infração penal – eis aqui outra das inúmeras justificativas para um Direito Penal de intervenção mínima –, o Direito se curva à necessidade de flexibilização na interpretação até mesmo de garantias constitucionais.

A expressão “exclusivamente”, portanto, não deve ser entendida como uma porta aberta para a livre valoração do material produzido na investigação, se presentes outras provas colhidas na instrução criminal. Não. Fosse assim, o convencimento judicial poderia ser construído com base essencialmente – e não exclusivamente! – em elementos informativos, bastando apenas a referência à existência de outras provas produzidas em Juízo.

Parece-nos que o tal “exclusivamente” apenas autorizaria um juízo de ponderação, de forma e principalmente de conteúdo, acerca das provas repetidas em Juízo, isto é, sobre a prova colhida na investigação e repetida em juízo'. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência – 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. pp. 410/411). (Negritei).

Na mesma ordem de ideias, preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Adotado o sistema da persuasão racional, o juiz pode formar livremente o seu convencimento, desde que fundamente a decisão (art. 155, CPP). Sob o prisma constitucional, seguindo-se o devido processo legal, as provas válidas para a condenação devem ser extraídas do processo judicial, em que há a ampla defesa e o contraditório. Algumas provas podem advir do inquérito policial, quando são periciais e feitas, à época do crime, com urgência (ex.: laudo de local). Em nossa visão, provas que podem ser refeitas em juízo (como a testemunhal), quando realizadas na fase extrajudicial, são inúteis para fundamentar a condenação do réu. (Processo penal e execução penal, 5. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 82). (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação de que a condenação apenas pode ser arrimada em elementos informativos coligidos no inquérito policial quando estes forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, sob a lente do contraditório:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal.

2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.

(...).

5. Recurso em habeas corpus não provido.” (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

Logo, em atenção do princípio do in dubio pro reo, a absolvição dos acusados, por falta de provas da materialidade do crime, tendo em vista a não comprovação da elementar subjetiva do delito, é medida de rigor.

Em caso análogo, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) - PLEITO CONDENATÓRIO - Impossibilidade. Frágil conjunto probatório. Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a manutenção da absolvição dos acusados, em respeito ao princípio 'in dubio pro reo'.

Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 1500342-82.2018.8.26.0655, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo Rossi, j. 22.07.2022).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO os acusados ANDRÉ JOSÉ DA SILVA, vulgo "Deka", e CARLOS EDUARDO MACHADO, vulgo "Carlinhos", qualificados nos autos, da imputação que lhes foi feita, por incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Em razão do presente desfecho decisório, ORDENO a cessação de eventuais medidas cautelares fixadas nestes autos (art. 386, parágrafo único, II, do CPP).

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do nobre patrono nomeados no valor máximo previsto na tabela vigente.

Porque órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal.

Transitada em julgado, proceda-se às anotações e às comunicações necessárias, arquivando-se definitivamente os autos.

P. I. C.

Piraju, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA